

1500125-39.2021.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... sentido:

"APELAÇÕES - Tráfico de drogas e Associação para o tráfico (art. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006) - (...). Crime de Associação para tráfico - Conjunto probatório frágil - Ausência de elementos suficientes que demonstrem a estabilidade, permanência e divisão de tarefas entre os corréus - Absolvição reconhecida, nos termos do art. 386, VII, do CPP - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500125-39.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500125-39.2021.8.26.0621

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2020972/2021 - DEL.POL.LORENA, 15836539 - DEL.POL.LORENA, 85/21/204 -

DEL.POL.LORENA, 2020972 - 02º D.P. LORENA, 85/21/204 - 02º D.P. LORENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO WILLIAN DOS SANTOS SILVA e outros

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de MARCELO WILLIAN DOS SANTOS SILVA, MARCOS CARVALHO DOS REIS e MARIA CECILIA DE CAMPOS ALMEIDA, qualificados nos autos, na qual lhes são atribuída a prática dos crimes previstos nos artigos 33, "caput", e 35, "caput", ambos da Lei 11.343/06, pelos fatos narrados na peça inicial de fls. 119/1121.

Oferecida a denúncia, os réus foram notificados, apresentando defesas prévias (fl. 160, Marcos; fls. 161/166, Maria Cecília; e fls. 167/168, Marcelo). Não sendo caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida no dia 28/07/2021, com designação de audiência de instrução e julgamento, nos termos do artigo 56, da Lei de drogas

(fls. 169/175).

No curso da instrução foram ouvidas as testemunhas, sendo os réus, ao final, interrogados. Na sequência, as partes apresentaram alegações finais em audiência (mídia às fls. 222).

O Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, com a condenação dos acusados, nos exatos termos da denúncia, afastando-se as atenuantes da confissão, por considerá-las apenas parciais.

Por sua vez, a defesa de Marcelo, diante de sua confissão, requereu o reconhecimento dessa atenuante, com a fixação da pena no mínimo legal, e o regime inicial aberto.

A defesa da corré Maria, pleiteou a improcedência da ação penal, com fulcro no artigo 386, inciso IV ou V, do Código de Processo Penal – CPP. Em caso de condenação, requereu a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06, ou, em caso de condenação nos termos da exordial, que seja aplicada a pena mínima, e reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Por fim, pleiteou a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Por fim, a defesa técnica do acusado Marcos requereu improcedência da ação penal, sustentando inexistirem provas do tráfico, bem como da associação, argumentando ter restado comprovado nos autos, unicamente a responsabilidade da corré. Subsidiariamente, em caso de condenação, pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão, com estabelecimento da pena no piso, e regime inicial menos severo.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

As materialidades delitivas encontram-se cabalmente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 01/04), auto de prisão em flagrante (fls. 27/28), auto de exibição e apreensão (fls. 31/32), fotografia (fls. 38), laudo de constatação provisória (fls. 50/52) e laudo químico toxicológico definitivo (fls. 103/105), cujos resultados foram positivos para “cocaína”, substância presente na lista da Portaria SVS/MS 344/98, e atualizações posteriores; bem como as provas orais existentes nos autos.

Com relação à autoria, tenho que esta igualmente restou demonstrada nos autos, ao menos, quanto ao tráfico de drogas, conforme passo a expor.

O policial militar Marcos Vinícius Guatura Tobias Lima confirmou a narrativa da denúncia, afirmando que já conhecia a ré, por ter sido presa dias antes, também pelo narcotráfico, desconhecendo os demais acusados até o dia dos fatos. Contou que só localizou e abordou os réus, naquela ocasião, vez que a própria acusada os indicou. Questionado, o depoente esclareceu que os réus não negaram suas responsabilidades pelos entorpecentes apreendidos.

No mesmo sentido depôs seu companheiro de farda, Zaqueu Siqueira Azarias. Referido declarante ainda explicou não ter sido possível identificar o automóvel (seu condutor) que, possivelmente, estava comprando entorpecentes da ré. Asseverou, ao cabo de suas declarações, que todos já eram conhecidos “nos meios policiais” pelo envolvimento anterior com o tráfico de drogas.

Em seu interrogatório, Maria confessou parcialmente os fatos. Contou que, de fato, estava vendendo entorpecentes no local dos fatos, contudo, negou que tenha indicado os corréus, afirmando que sequer os conhece. Questionada como os policiais

militares chegaram até os réus, narrou que havia várias viaturas policiais no local, sendo que, enquanto uma abordava ela, outra já estava com os acusados.

No ato destinado a sua autodefesa, o corréu Marcelo igualmente optou por assumir a responsabilidade do fato que lhe é atribuído. Contou que a acusada o havia contratado para ficar de "olheiro" dos entorpecentes sob responsabilidade dela. Afirmou que ganharia pelo serviço, duas cápsulas de "cocaina" (uma para ele, e outra para o corréu Marcos). Questionado, disse que não conhecia a acusada até aquele dia. O acusado asseverou que, devido ao seu vício, resolveu aceitar a proposta da ré. Afirmou que visualizou o momento em que a increpada os apontou aos policiais militares, assim como, mostrou a estes, a localização dos entorpecentes.

Versão idêntica apresentou o corréu Marcos em seu interrogatório.

Eis, portanto, o cenário probatório.

Pois bem. Como se vê, a autoria dos réus está confirmada por suas confissões espontâneas, em consonância com demais provas dos autos.

Destarte, sem prejuízo da confissão dos acusados, na medida em que existe interesse público em jogo, vez que as declarações dos réus não estão totalmente em linha com a denúncia, deve o Juiz analisar a postura deles frente as demais provas, verificando se há convergência ou divergência no cotejar de todas elas.

No caso dos autos, a confissão judicial isenta de vícios e coações, como a trazida pelos increpados, fornece elemento seguríssimo de prova, que por si só serve de lastro para a condenação deles pelo crime de tráfico, exceto se, por outros elementos de convicção, a palavra desses réus soasse inverídica, com relação à responsabilidade criminal pelas condutas aqui imputadas, o que não aconteceu no presente caso.

Veja-se que, embora com algumas nuances, Maria assumiu que estava "vendendo" entorpecentes, admitindo que o dinheiro apreendido em sua posse seria fruto da venda de narcóticos, conduta esta tipificada no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Saliente-se que tal enredo vai ao encontro do que falaram as testemunhas policiais responsáveis por sua prisão em flagrante, os quais disseram que a flagraram entregando algo para o condutor de um veículo, o qual deixou o local rapidamente, ao vê-los, em cena típica do tráfico.

De igual modo, os réus Marcos e Marcelo confessaram estarem "guardando" as drogas, outra conduta também tipificada no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Decerto, ainda que esses acusados tenham negando a prática de qualquer ato de mercancia, convém esclarecer que o crime previsto no artigo 33, "caput" da Lei de Tóxicos não se limita a conduta de "vender", já que há previsão neste tipo penal de diversas outras condutas, salientando-se que a finalidade mercantil deve estar demonstrada pelas circunstâncias do caso, na hipótese dos autos: a quantidade de entorpecentes apreendidos (mais de cem pinos plásticos, do tipo "eppendorf"); além da própria negociação espúria entabulada entre a ré e o motorista de um veículo, cuja identidade não foi possível revelar.

A propósito:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recurso defensivo - Autoria e materialidade delitivas comprovadas - Prisão em flagrante e firmes depoimentos dos policiais militares - Desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 - Descabimento - Tipo penal que prevê diversas condutas -

Desnecessidade da prova da efetiva mercancia - Condenação mantida - (...) Recurso não provido". (TJSP; Apelação Criminal 1500932-98.2019.8.26.0566; Relator: Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019) (Ênfase na reprodução).

Insta salientar, também, que o fato de os réus declararem serem usuários de drogas não afasta a tipicidade de suas condutas, pelo artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, afinal, não é incompatível com o fato de também serem traficantes.

Como é de notório conhecimento, não raro usuários passam a vender drogas ou guardá-las para outros traficantes com o fim de financiar a própria dependência, o caso da ré e dos réus, respectivamente.

Todavia, nos presentes autos, a quantidade dos entorpecentes apreendidos excedem a de simples usuário, principalmente, porque, neste caso, foi apreendido valor em dinheiro e Maria foi surpreendida pelos policiais vendendo, não se podendo falar em desclassificação para o artigo 28, da mesma Lei, como alegou a defesa dessa ré.

Seguem julgados com o mesmo entendimento:

"Apelações criminais. (...) Não há possibilidade de se desclassificar as condutas para mero porte de drogas, certo que a jurisprudência não descarta a figura do usuário/traficante. 2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o tráfico aos apelantes e apelado (...) 6-) Recursos presos". (TJSP; Apelação Criminal 0001106-76.2017.8.26.0559; Relator: Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 05/12/2019; Data de Registro: 06/12/2019); e

"Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, caput, e § 4º da Lei 11.343/06 (...) Condição de usuário não tem o condão de descaracterizar o crime do artigo 33 da referida norma, a qual possui conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, sendo o bastante para a sua caracterização a prática de apenas uma delas (...) Dado parcial provimento ao recurso". (TJSP; Apelação Criminal 0002190-02.2017.8.26.0628; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 02/12/2019) (Sublinhados meus).

Assim, conforme a explicação de JÚLIO FABBRINI MIRABETE, "a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

Isso ocorre porque os depoimentos dos policiais militares, que realizaram a prisão em flagrante dos réus, corroboraram com as suas versões.

Neste ponto, insta registrar que aqueles que acompanham de perto as decisões deste Magistrado, bem sabem a credibilidade que costume conferir às palavras dos policiais, sejam eles, militares, civis, federais, rodoviários federais, guardas municipais, ou mesmo, qualquer outro agente de segurança pública, seguindo, aliás, a maioria da jurisprudência dos nossos tribunais.

Confira-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça - STJ e do Tribunal de Justiça deste estado - TJSP:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o

crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido". (STJ; AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC; Relator: Ministro Ribeiro Dantas; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data da publicação: 23/03/2020); e

"Apelação criminal. Tráfico de entorpecente. Materialidade delitiva demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da substância entorpecente, laudo de exame químico-toxicológico e prova oral. Autoria comprovada pela palavra de testemunhas policiais - Depoimentos insuspeitos e harmônicos, suficientes para alicerçar o decreto condenatório - Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos - (...) Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1514240-51.2019.8.26.0228; Relator: José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020) (Ênfase na reprodução).

Anoto ainda que o fato de Maria em juízo negar que tivesse delatado os outros corréus, indicando a participação deles no vil comércio, na função de guardar as drogas, não afasta as autorias destes, e muito menos a dela.

Primeiro, porque aquela confessou ser a proprietária de todos os entorpecentes, em linha com as autodefesas de Marcos e Marcelo, e, ainda que tal circunstância já fosse suficiente para sua condenação pelo artigo 33, da Lei de drogas, ela, também, assumiu a mercancia.

Segundo, porque esses acusados, como se viu acima, igualmente confessaram que estavam guardando os entorpecentes para Maria, em troca de pinos plásticos, para juntos consumirem.

Portanto, o caso de condenação do trio pelo crime de tráfico de drogas.

Lado outro, quanto a imputação remanescente, o destino dos acusados é a absolvição.

Com efeito, de acordo com o conjunto probatório dos autos, entendo não haver prova suficiente para se concluir, com um mínimo de segurança, que os réus estavam associados, para o comércio ilícito de entorpecentes.

Convém lembrar que não basta para subsumir a conduta em estudo ao tipo do artigo 35, da legislação de drogas, a presença de dois ou mais agentes. É imprescindível que se revele o "animus associativo", a estabilidade, permanência e organização do grupo, com funções pré-determinadas entre seus membros, bem como relação de hierarquia entre eles.

Ressalto que, embora os elementos dos autos tenham apontado uma repartição de tarefas, ficando Marcos e Marcelo responsáveis pela guarda das drogas e Maria pela venda no varejo, diante do contraditório e ampla defesa, nada foi trazido aos autos, de modo a demonstrar a estabilidade e permanência, como requer a tipificação do artigo 35, conforme exposto no parágrafo acima.

De fato, não há elementos a demonstrar a "associação" entre eles para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, "caput" e § 1º, e 34, da Lei 11.343/06, dado que as provas orais se limitaram em dizer que, no momento do flagrante, Marcos e Marcelo guardavam as drogas de propriedade de Maria, enquanto esta as vendia.

Nota-se que os acusados disseram que sequer conheciam Maria até aquele dia, quando, resolveram aceitar a proposta dela para guardarem os entorpecentes, tudo indicando

que por uma única vez, sem qualquer intenção de associação, ou seja, sem estabilidade e permanência.

Nesse sentido:

"APELAÇÕES - Tráfico de drogas e Associação para o tráfico (art. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006) - (...). Crime de Associação para tráfico - Conjunto probatório frágil - Ausência de elementos suficientes que demonstrem a estabilidade, permanência e divisão de tarefas entre os corréus - Absolvição reconhecida, nos termos do art. 386, VII, do CPP - Recurso parcialmente provido". (TJSP; Apelação Criminal 0001600-86.2013.8.26.0459; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pitangueiras - 1ª Vara; Data do Julgamento: 15/09/2020; Data de Registro: 15/09/2020) (Sublinhado meu).

Portanto, devida a absolvição dos réus da imputação prevista no artigo 35, "caput", da lei citada, visto que no processo penal, em regra, o ônus da prova recai sobre quem alega, conforme 156, do CPP.

Passo à calibragem penal, pelo crime de tráfico, seguindo a ordem da denúncia.

a) MARCELO WILLIAN DOS SANTOS SILVA:

Nos termos do artigo 42, da Lei de Drogas, o juiz na aplicação da pena deve considerar, com preponderância às circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, a natureza, quantidade, personalidade e conduta social.

Ainda que o réu seja primário e sem antecedentes criminais, a quantidade de narcóticos apreendidos (71,70 gramas, peso líquido, de "cocaína", distribuídos em 122 pinos plásticos prontos para venda), apontam para maior risco ao bem jurídico tutelado por este tipo penal, a saúde pública, não podendo este julgador, aplicar a mesma sanção devida à culpabilidade normal à espécie.

Anoto, também, que a presença de dinheiro com os réus demonstra que o tráfico de drogas rendeu frutos, concretizando-se um dano à saúde pública, com a venda de entorpecentes.

Logo, sua pena-base deve ser fixada em 1/8 (um oitavo) acima do mínimo legal, ou seja, em 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, logo, atenuo as suas penas, retornando-as ao piso legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multas, por ser inviável fixá-las abaixo desse patamar, conforme jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 231: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Inexistem agravantes.

Na última etapa, reconheço o privilégio do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, por tratar-se de réu primário e sem antecedentes, e não haver provas minimamente robustas indicando que Marcelo integrasse organização criminosa, ou mesmo que se dedicasse às atividades criminosas dessa natureza.

Logo, aplico a redutora no seu patamar máximo, reduzindo a pena em 2/3 (dois terços), e finalizando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, definitivamente, à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

b) MARCOS CARVALHO DOS REIS:

O réu é igualmente primário e sem antecedentes criminais (fls. 56 e 55).

Todavia, tal como apontado na dosimetria referente a Marcelo, observadas as diretrizes do artigo 42, da Lei de drogas, tenho que a conduta de Marcos merece maior reprovação, pelas razões lá aduzidas.

Logo, mantendo a proporcionalidade, a basilar será igualmente no mesmo percentual de 1/8 (um oitavo) acima do mínimo legal, ou seja, em 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa.

Na etapa intermediária, reconheço também a atenuante da confissão espontânea, reduzindo, assim, as sanções aos mínimos legais, por ser impossível fixá-las abaixo desse piso, conforme súmula mencionada na dosimetria anterior. Não existem agravantes.

Na terceira etapa, presente a causa de diminuição da pena do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, por tratar-se de réu primário e sem antecedentes, e não haver provas seguras de que integrasse organização criminosa, ou mesmo de que se dedique às atividades criminosas dessa natureza, conforme fundamentado acima para Marcelo.

Assim, diminuo as penas na fração máxima para estabelecê-las definitivamente, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, por não haver outras circunstâncias alteradoras.

c) MARIA CECILIA DE CAMPOS ALMEIDA:

A ré, assim como os corréus, é primária e sem antecedentes, conforme folha de antecedentes (fl. 59) e certidão criminal (fls. 57/58).

Contudo, presente as mesmas circunstâncias judiciais desabonadoras mencionadas nas dosimetrias dos acusados Marcos e Marcelo, com relação à quantidade das drogas e dinheiro, conforme o artigo 42, da Lei de Drogas.

Assim, mantendo a proporcionalidade, fixo a pena-base com elevação de 1/8 (um oitavo) do mínimo legal, ou seja, em 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa.

Na segunda fase, verifico a incidência de duas atenuantes: a confissão espontânea, e a menoridade relativa. Porém, as sanções não podem ficar abaixo do piso da lei, conforme súmula mencionada acima.

Registro que aqui reconheci a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que a ré confessou a traficância, embora tenha sido parcial, em consonância com as confissões dos outros acusados, também, consideradas em suas dosimetrias.

Nesse sentido:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão parcial de RONALDO, admitindo a traficância e isentando as corrés de responsabilidade. Negativas das acusadas isoladas do conjunto probatório. (...) Condenações mantidas. Apelo ministerial buscando o afastamento, na terceira fase, do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 para as rés, e a fixação do regime fechado. Admissibilidade. 1) Réu RONALDO: básicas estipuladas em um terço acima dos pisos legais, diante da razoável quantidade e variedade de drogas, além dos maus antecedentes, o que está justificado e fica mantido. Na fase seguinte, de rigor o reconhecimento da atenuante da confissão, eis que o réu admitiu participação no tráfico de drogas, embora tenha isentado as corrés. Penas que são reduzidas na fração de um sexto, tornando-se definitivas nesses patamares. (...). 4) Apelo de

RONALDO parcialmente provido, recursos de FERNANDA e GIOVANNA improvidos e irresignação ministerial acolhida". (TJSP; Apelação Criminal 1511195-39.2019.8.26.0228; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/12/2021; Data de Registro: 16/12/2021) (Original sem marcação).

Em consonância com a jurisprudência sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:

"Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". (SÚMULA 545, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015). Não existem agravantes.

Na terceira e última etapa, não havendo outras circunstância modificadoras das penas, torno definitivas as penas outrora lançadas, no importe de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Esclareço não fazer jus a acusada à redutora prevista no parágrafo quarto, do artigo 33, da Lei de Drogas, ao contrário dos corréus, na medida em que as circunstâncias do caso concreto, evidenciam sua profunda intimidade com o narcotráfico e, portanto, sua dedicação às atividades criminosas, ainda que seja considerada primária e de bons antecedentes, aos olhos da lei.

Note-se que, segundo a própria ré e as declarações dos acusados, as drogas eram de sua propriedade, assim como o valor em dinheiro apreendido ficariam em seu poder, vez que os réus receberiam parte das drogas como pagamento, a demonstrar que estava fazendo o vil comércio o seu meio de vida.

Em reforço a tal conclusão, cito o fato da acusada sequer ter comprovado o desenvolvimento de ofício legítimo à época dos fatos.

Bem se sabe que aqueles que fazem do tráfico de drogas um meio de vida, não fazem jus ao benefício, dado que essa causa de redução da pena é destinada àquele que age por um impulso, em situação isolada no tráfico de drogas, incidindo na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida da ré, não sendo o caso destes autos, quando a mesma é surpreendida com mais cem pinos plásticos, contendo cocaína, prontos para o vil comércio e dinheiro, a demonstrar que já havia realizado diversas vendas.

Outro não é o entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça:

"Tráfico de entorpecentes. (...) Insurgência defensiva em face da pena. Reprimendas irreprocháveis. Impossibilidade de reconhecimento de tráfico privilegiado. Benefício ao qual não fazem jus às acusadas. Dedicação à atividade criminosa. Volume considerável de droga que revela não serem as rés meras aventureiras no ramo da narcotraficância (...) Precedentes do STJ. Negado provimento ao apelo". (TJSP; Apelação Criminal 0002163-92.2017.8.26.0539; Relator: Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 01/02/2020) (Original sem marcação).

Outra circunstância que comprova a dedicação da acusada ao vil comércio é que seu histórico pessoal configura impeditivo do reconhecimento dessa benesse, ainda que não possa ser utilizado como mau antecedente.

Decerto, é de conhecimento deste Juízo que Maria Cecília responde a outra ação penal, em trâmite neste Juízo, pela prática deste delito grave delito, ora julgado, deixando clara sua dedicação perene ao narcotráfico (fls. 57/58 - autos nº 1500094-19.2021.8.26.0621).

Observe-se que, seis dias após ser colocada em liberdade por aquele processo, em audiência de custódia, a ré foi presa em flagrante, novamente por tráfico de drogas.

A propósito, informativo do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

"É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06". (Informativo nº 0596, Publicação: 1º de março de 2017; EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, por maioria, julgado em 14/12/2016, DJe 1/2/2017).

Com relação ao regime inicial de cumprimento das penas, anote-se que o delito de tráfico é equiparado aos crimes hediondos, de acordo com a atual redação do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 e, por isso, não se mostra razoável a incidência do regime aberto ou semiaberto para o cumprimento da reprimenda, em que pese não seja obrigatório o regime mais gravoso, devido ao C. Supremo Tribunal Federal – STF ter reconhecido, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do parágrafo citado (HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli).

Porém, convém lembrar, na esteira do julgado citado da Suprema Corte, que isso não invalida a discricionariedade judicial, com possibilidade na análise do caso concreto, de fixação do regime fechado quando entendido como sendo o mais adequado.

No caso dos autos, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado para Maria, em vista das circunstâncias concretas destes autos acima expostas, como da quantidade de entorpecentes e dinheiro apreendidos, forte no artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Veja-se:

"Tráfico de entorpecentes – Agente que traz consigo 34,2 gramas de cocaína sob a forma de "crack", 31,2 gramas de cocaína e 16 gramas de maconha – (...) Regime inicial – Tráfico de entorpecentes – Imposição legal do sistema fechado para início do cumprimento de pena – Não subsistência do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90 – Entendimento da Resolução n. 5/2012 do Senado Federal – Fixação que continua a ser regida pelos parâmetros objetivos e subjetivos contidos nos artigos 33, § 3º e 59, do CP. O entendimento predominante nos tribunais tem sido no sentido de que, em se cuidando de tráfico de entorpecentes, não mais subsiste a vedação legal (art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90) à fixação de regime inicial para cumprimento de pena privativa de liberdade diverso do fechado. O entendimento lastrea-se no fato do Senado Federal ter editado a Resolução n. 5/2012, pela qual cessou a executoriedade da proibição da conversão da pena de prisão imposta em mera restrição de direitos. Se não mais existe óbice à referida conversão, com muito mais razão não se poderia subtrair do Magistrado a ampla liberdade na fixação do regime inicial para cumprimento de pena. O regime inicial para cumprimento de pena continua, todavia, sendo fixado consoante os parâmetros enumerados no art. 59 do CP, ao qual faz remissão o art. 33, § 3º, do CP, de modo que, para ser adotado de regime de pena mais brando o sentenciado deverá preencher não apenas os requisitos objetivos, mas também aqueles de natureza subjetiva. (...)" (TJSP; Apelação Criminal 1500363-78.2018.8.26.0616; Relator: Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 24/05/2013; Data de Registro: 11/03/2020) (Ênfase nas reproduções).

Ademais, em se tratando de tráfico de drogas, distinto da figura privilegiada, estabelecer regime inicial diverso do fechado acabaria por também por ofender todo o arcabouço legal relativo à prevenção e reprovação do tráfico de drogas, já que a Constituição Federal, nossa lei maior, em seu artigo 5º, incisos XLIII e LI,

estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, autorizando até mesmo a extradição de brasileiro naturalizado, de forma a harmonizar a legislação pátria aos tratados internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário, não havendo razão para que, neste caso concreto, não dê cumprimento as essas políticas-criminas assumidas.

Por outro lado, o regime inicial para os acusados Marcos e Marcelo será o aberto, em consonância com o quanto disposto no artigo 33, §§ 2º, alínea "c", e 3º, do Código Penal.

Com relação à substituição da pena privativa de liberdade ou mesmo a aplicação do sursis, cerro fileiras com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no incidente de arguição de inconstitucionalidade, no "habeas corpus" nº 120.353 - SP, pois, a individualização da pena é tarefa que incumbe primeiramente à lei e disso o legislador se desincumbiu engendrando a proibição descrita no artigo 44, da Lei 11.343/06.

No mais, tenho por irretorquíveis os argumentos expostos na ementa do referido remédio constitucional, abaixo transcrita, vez que em linha com o princípio da individualização da pena e com a vontade do legislador constitucional:

"ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INCONVERSIBILIDADE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 33, § 4º E ART. 44, CAPUT, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. Se a lei deve assegurar indiscriminadamente ao juiz o arbítrio para, no caso do tráfico ilícito de entorpecentes, substituir a pena privativa da liberdade pela pena restritiva de direitos, o próprio art. 44 do Código Penal seria inconstitucional ao excluir desse regime os crimes cometidos à base da violência ou de grave ameaça à pessoa - e com maior razão. Com efeito, as hipóteses excludentes do regime de substituição de penas, contempladas no art. 44 do Código Penal, tem como suporte unicamente o critério do legislador ordinário; já a inconversibilidade das penas quando a condenação decorre do tráfico ilícito de entorpecentes têm por si a vontade do constituinte, que em dois momentos destacou a importância da repressão a esse crime, a saber: - primeiro, no art. 5º, XLIII, já citado, a cujo teor a lei considerará inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, dentre outros, o tráfico ilícito de entorpecentes; - segundo, no art. 5º, LI, que autoriza a extradição do brasileiro naturalizado comprovadamente envolvido no tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Arguição de inconstitucionalidade rejeitada". (STJ; AI no HC 120.353/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Rel. p/ Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2009, DJe 18/12/2009).

Afinal, não se afigura socialmente recomendável a reinserção de réus condenados pelo tráfico de "cocaína" ao convívio social, indicando-lhes instituições públicas (escolas, asilos, centro de saúde etc.) para prestar serviços comunitários!

De fato, tais medidas mostrar-se-iam insuficientes e ineficazes à reprovação, dada a hediondez do crime de tráfico.

Ressalto, mesmo para os acusados que foram beneficiados com o § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, atualmente não mais considerado hediondo, sobretudo, após a revogação da Súmula 512, pelo Superior Tribunal de Justiça; como o tráfico privilegiado não impõe a substituição ou o sursis de forma automática, a pena privativa de liberdade revela-se a única resposta penal efetivamente apta a atender ao requisito preventivo-retributivo da reprimenda, na medida em que repreende o acusado, pelo grave crime de tráfico de drogas, ainda que privilegiado, não se afigurando socialmente recomendável, as referidas substituição e suspensão da pena.

A propósito, entendimento recente do Tribunal de Justiça deste estado:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição - Viável admissão do tráfico privilegiado previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Penas readequadas e fixado o regime aberto aplicado - Possibilidade - Afastamento do caráter hediondo do tráfico privilegiado pela Lei nº 13.964/2019 - Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos - Recurso parcialmente provido". (TJSP; Apelação Criminal 1500028-48.2021.8.26.0424; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pariqueira-Açu - Vara Única; Data do Julgamento: 08/09/2021; Data de Registro: 08/09/2021) (Sublinhado meu).

Portanto, deixo de aplicar qualquer medida despenalizadora ao caso.

Por fim, fixo o dia-multa no piso legal para os acusados, com base no salário-mínimo na data dos fatos, atualizado até o momento do seu efetivo pagamento, por serem parcas as informações acerca da situação financeira deles, forte no artigo 43, da Lei 11.343/06.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

- a) condenar MARCELO WILLIAN DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, a uma pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, diária mínima (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos), com valor total da pena de multa a ser atualizado nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal;
- b) condenar MARCOS CARVALHO DOS REIS, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, a uma pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, diária mínima (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos), com valor total da pena de multa a ser atualizado nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal;
- c) condenar MARIA CECÍLIA DE CAMPOS ALMEIDA, qualificada nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, a uma penas de 05 (cinco) anos reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, diária mínima (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos), com valor total da pena de multa a ser atualizado nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal; e
- d) absolvê-los da imputação restante que lhes foram irrogadas na denúncia (artigo 35, "caput", da Lei 11.343/06) na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nego à ré Maria o direito de recorrer em liberdade. Com efeito, na data de hoje, os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que até então sustentavam a prisão preventiva da implicada se transformaram em certeza, por meio de cognição exauriente.

Além disso, a pena relativamente alta imposta à acusada e o estabelecimento de regime inicial mais severo de cumprimento de pena aplicado na sentença traduzem risco concreto de fuga real, em caso de sua soltura nesta quadra processual.

Ademais, não faz qualquer sentido soltar uma ré que permaneceu segregada durante toda a instrução processual, agora, depois de condenada, sem que tenha dado o tempo da providência de que trata o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, salientando-se que Maria Cecília foi presa em flagrante seis dias após ter sido

colocada em liberdade.

Assim, visando não só assegurar a aplicação da lei penal, como também, garantir a ordem pública, recomende-se a acusada na prisão em que se encontra.

Sobre o assunto, confira-se o entendimento do E. TJSP:

"Tráfico de Drogas - Preliminar - Apelo em liberdade - Impossibilidade - Requisitos do artigo 312 do CPP preenchidos - Preliminar rejeitada - Recurso não provido. Tráfico de Drogas - (...) - Recursos providos em parte". (TJSP; Apelação Criminal 0000864-07.2017.8.26.0628; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020) (Sublinhado meu).

Mesmo entendimento das Cortes Superiores: "não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Havendo recurso, expeça-se guia de execução provisória.

Concedo, outrossim, aos réus Marcos e Marcelo, o apelo em liberdade, considerando o regime inicial ora imposto. Expeçam-se alvarás de soltura clausulados em favor desses réus.

Custas pelos vencidos, observada a gratuidade de justiça, que ora lhes concedo.

Expeçam-se certidões de honorários advocatícios às advogadas nomeadas, de acordo com o previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Registro que a autoridade policial já está ciente da autorização para a destruição dos entorpecentes e demais apetrechos, conforme fl. 138.

Quanto ao dinheiro apreendido e depositado em juízo, decreto o perdimento em favor da União, por se tratar de produto do vil comércio, visto ter sido apreendido nesse contexto, conforme comprovado pelos depoimentos das testemunhas acima. Expeça-se o necessário após o trânsito em julgado.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeçam-se os mandados de prisão e, com o cumprimento desse mandados, a guia de execução definitiva, ou o seu complemento, conforme o caso; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação dos réus, com suas devidas identificações, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; d) Oficie-se a autoridade policial nos termos do artigo 72, da Lei 11.434/06, sobre a amostra guardada para contraprova; e e) Adotadas as cautelas legais, com o cadastramento dos processos de execução, arquivem-se com baixa.

P.I.C

Lorena, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA